

1513650-06.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Pereira de Castro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... a solicitação do menor. Negou a prática do tráfico.

Foi o que se colheu do contraditório, tornando certas autoria e materialidade delitivas.

A prova reunida basta para a condenação. O réu e o menor foram visualizados em situação típica de tráfico de drogas, inclusive, com flagrante de mais de uma venda realizada pelos agentes. Além disso, corroborando a percepção dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1513650-06.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513650-06.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS MAURICIO DA SILVA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

LUCAS MAURICIO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput cc art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, pois, segundo a denúncia, em 03 de junho de 2021, por volta das 14h20min, na Rua Vladimir Sinkus, altura do numeral 196, Vila Curuçá, nesta cidade e comarca da Capital/SP, LUCAS MAURICIO DA SILVA qualificado a fls. 12, agindo em concurso com o adolescente Geovane de Luca Coimbra dos Santos, caracterizado pelo vínculo subjetivo e unidade de desígnios, em ocasião de calamidade pública, guardavam, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, aproximadamente 43,8g (quarenta e três gramas e oito decigramas) da droga cocaína, acondicionados em 43 (quarenta e três) microtubos plásticos, tipo "Eppendorf", fazendo-o sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação de fls. 33/35). Segundo restou apurado, na data, hora e local acima indicados, LUCAS e o adolescente Geovane encontravam-se no local dos fatos realizando o tráfico de entorpecentes, sendo que guardavam, próximo ao local em que atendiam aos usuários, diversas porções individualizadas da droga cocaína.

Assim, enquanto realizavam o comércio espúrio, foram observados por policiais civis, que realizavam diligências pelo local, que era conhecido como ponto de venda de drogas. Assim, após efetuada campana, os policiais avistaram LUCAS e o adolescente juntos, em atitude típica de tráfico de entorpecentes. Observaram que o adolescente atendia aos usuários, que estava em veículos, recebendo deles dinheiro e, na sequência, entregando a eles as drogas. O dinheiro recebido pela venda da droga, o menor entregava para LUCAS, que o escondia. Também observaram LUCAS e o menor atendendo juntos a uma transeunte.

Diante de tal situação, os policiais decidiram efetuar a abordagem da dupla. Em busca pessoal, localizaram com o adolescente a quantia de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). Nas proximidades em que os autores estavam, os policiais encontraram guardadas, em uma lixeira, 43 invólucros plásticos contendo cocaína.

Inquiridos, o menor disse ser o responsável pela venda dos entorpecentes, e, conforme as porções iam acabando, eram abastecidas. Todavia, ao serem indagados sobre quem fornecia as drogas, por quanto as vendiam e quanto ganhavam ao final do dia, nada falaram.

A denúncia foi recebida a fls. 166/169 e o réu apresentou defesa preliminar a fls. 162/165.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o representante do Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela procedência da ação penal e, em atenção à gravidade do crime, equiparado aos crimes hediondos, requereu o início do cumprimento no regime fechado.

A Defesa, noutro giro, em memoriais, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente, a despeito da combatividade da Defesa, condenando-se o réu pela prática do crime do artigo 33, caput, cc art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo apurado, na data indicada na denúncia, o réu e o adolescente Geovane encontravam-se no local dos fatos realizando o tráfico de entorpecentes, sendo certo que guardavam, próximo ao local em que atendiam aos usuários, diversas porções individualizadas da droga cocaína.

Nesse contexto, enquanto realizavam o comércio espúrio, foram observados por policiais civis, que realizavam diligências pelo local, já conhecido como ponto de venda de drogas. Os agentes públicos avistaram LUCAS e o adolescente juntos, em atitude típica de tráfico de entorpecentes, pois o adolescente atendia aos usuários, que estavam em veículos, recebendo deles dinheiro e, na sequência, entregava a eles as drogas. O valor era repassado a LUCAS, que escondia o numerário. Os policiais ainda visualizaram o momento em que ambos atenderam a uma transeunte.

Diante de tais fatos, deliberaram pela abordagem e, em busca pessoal, localizaram R\$ 54,00 em poder do menor. Nas proximidades em que estavam o réu e o menor, em uma lixeira, localizaram 43 porções de cocaína. Em razão disso, o réu foi detido e conduzido à delegacia de polícia.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos, de forma a estabelecer perfeita correlação entre o material apreendido, aquele submetido à avaliação preliminar e, finalmente, o exame toxicológico.

A autoria é igualmente certa.

O policial civil José Roberto Pereira Bersani Júnior disse que, juntamente com outro policial, na data dos fatos, realizavam diligências visando a repressão ao tráfico de drogas, em vista de muitas denúncias sobre o comércio ilícito na região. O menor indicou o local onde estava a droga, de onde era retirada para repassar aos usuários; com ele não encontraram dinheiro, que foi localizado em poder do acusado.

A droga estava escondida numa lixeira, porções de cocaína. Somente o menor confessou; o réu e a outra pessoa detida no momento não disseram nada. Segundo o menor, ele entregava o dinheiro recebido para o réu. Lucas, segundo disse o menor,

seria o responsável pela guarda do dinheiro. Reafirma que visualizaram o menor recebendo o dinheiro e entregando-o ao acusado Lucas. Talvez “tenha ocorrido um erro na elaboração do flagrante”. A função de Lucas seria, efetivamente, a guarda do dinheiro das vendas.

No mesmo sentido, em suma, o quanto narrado pela policial civil Rafaela Bertoletti, que ressaltou o fato de ser comum os menores serem colocados para efetivamente realizar o comércio das drogas sob a supervisão de um maior de idade, responsável pela arrecadação dos valores e guarda da droga.

A testemunha de Defesa, Conceição Maurício, disse que Lucas “já deu muito trabalho, porque ele é interditado” (sic). Ele “não para em casa, toma remédios para se matar” (sic). É mãe do acusado, motivo pelo qual seu depoimento foi colhido na condição de informante.

Em seu interrogatório, o réu disse que estava no local a fim de comprar um salgado, atendendo a solicitação do menor. Negou a prática do tráfico.

Foi o que se colheu do contraditório, tornando certas autoria e materialidade delitivas.

A prova reunida basta para a condenação. O réu e o menor foram visualizados em situação típica de tráfico de drogas, inclusive, com flagrante de mais de uma venda realizada pelos agentes. Além disso, corroborando a percepção dos policiais sobre a mercancia, foram apreendidos drogas e dinheiro. Assim, robusta a prova acusatória. A alegação comum da defesa, de ser necessária a exclusão dos depoimentos de testemunhas, por serem policiais, não procede.

O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção juris tantum de agir escorreitamente, presumindo-se ser legítima a sua atuação, sendo certo que como qualquer pessoa, pode ser testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade. Até mesmo porque o policial “deve no exercício das funções (e depor sobre suas ações constitui parte de seu mister) igualmente dizer a verdade, só não merecendo consideração se os indícios constantes dos autos o contrário revelem...”. Por estes motivos a simples condição de policial, conforme reconhece a Suprema Corte, não torna a testemunha impedida ou suspeita.

Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para sua suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende. Sendo, portanto, o depoimento policial plenamente válido, não podendo ser, aprioristicamente, desconsiderados em razão da condição de policial, máxime quando não contraditados em Juízo, o que serve de indício da lisura de sua atuação, afasta-se a alegação de falta de validade.

Vale destacar que, mesmo seja o vendedor também um usuário de entorpecentes, que assim procede na traficância para sustentar sua drogadição, não há se cogitar em absolvição ou desclassificação da conduta.

A lei já discrimina a figura daquele que, sendo usuário, fornece drogas, com caráter de eventualidade e sem visar lucro, a pessoa de seu círculo vicioso para juntos consumirem os entorpecentes – artigo 33, parágrafo terceiro, da Lei n. 11.343/2006.

Os papéis de usuário e traficante podem imbricar-se, sem que, com isso, se afaste a figura do tráfico.

Finalmente, não se cogita de absolvição imprópria, pois não demonstrada a incapacidade mental do réu. A Defesa, conquanto tenha sustentado a existência de uma patologia psíquica, não requereu a instauração do incidente de sanidade mental (arts. 149 e ss do CPP). Assim, a alegação não foi provada, ressaltando-se que o laudo de outro processo, juntado a fl. 117, concluiu que o réu possui inteligência dentro do normal e que não há distúrbios de percepção.

Passo, destarte, à dosimetria da pena.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, o fato de o réu ser primário e que não

guardava ou tinha em depósito quantidade absolutamente expressiva de entorpecente, entendendo suficiente à repressão e prevenção do crime a fixação da pena base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar. O réu é primário, como se depreende das certidões de fls. 57/59. Ainda, incabível a incidência do agravamento da pena em razão da calamidade pública, uma vez que a pandemia da COVID-19 não foi determinante para a prática do delito, em nada interferindo na consumação.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, reduzo a pena fixada em dois terços. Assim, estabeleço a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em face da majorante reconhecida (art. 40, VI), aplico o aumento de 1/6 (um sexto), resultando a pena total em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Fica estimada a diária no patamar básico ante sua parca condição econômica.

Possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, no caso dos autos.

Isso porque, considerando-se os fatores já enunciados do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei n. 11343/2006, quando se cuida de agente primário, de bons antecedentes e não dedicado a atividades criminosas e, mais, cuja quantidade de droga apreendida não seja expressivamente grave, temos a hipótese de réu com menor potencial de ofensividade à coletividade.

A Lei de regência deixou ao critério do julgador a discricionariedade de individualizar a pena do acusado e, nesse sentido, evidente que quis o legislador conferir ao réu que se enquadre no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei Federal n. 11343/2006 um 'status' jurídico diferenciado. Por isso mesmo que, "diante da possibilidade de imposição de pena diminuída, evidente que tanto a fixação do regime inicialmente fechado, como a impossibilidade de conversão da sanção alternativa, podem se tornar medidas excessivas e desproporcionais em relação ao crime de tráfico. A determinação da decisão do Pleno do STF de não se poder tirar do juiz a atividade de individualizar concretamente a sanção penal de acordo com a culpabilidade pelo fato praticado, representa, no dizer de Eduardo Correia, a arte de julgar do juiz criminal. Aí, na verdade, se afinam todas as nuances e particulares sentidos dos fins das penas; aí há que lançar mão de todos os ensinamentos da criminologia e da política criminal; aí se apuram todas as infinitas gradações dos vários momentos em que se analisa o crime".

O Supremo Tribunal Federal já decidiu desta maneira:

"A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos, nos crimes de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, o HC n. 93.857, Cezar Peluso, DJ 16.10.09 e o HC n. 99.888, de que fui relator, DJ 12.12.10. Ordem concedida para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos" (STF, 2ª Turma, HC 97.500, rel. Eros Grau, j. 25.05.2010).

No mesmo sentido, ainda junto ao C. STF:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Motivação idônea para a redução em grau intermediário. Recurso não provido. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. 1. Encontra-se convenientemente motivada a eleição do grau de redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Embora o paciente seja primário, a natureza da droga apreendida (42 pedras de crack) justificam a diminuição da pena em 1/3 (um terço). 3. Recurso não provido. 4. Impossibilidade de análise em sede recursal de temas não

apreciados nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo quando se trata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

(RHC 109374, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 05-12-2011 PUBLIC 06-12-2011)

O Senado Federal, por sua vez, através da Resolução n. 05, de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu a eficácia da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de regência, com fulcro no 'decisum' adotado no HC 97.256/RS. De outro ângulo, sabido e consabido (ou ao menos deveria sê-lo) que a opinião pessoal do julgador sobre a gravidade do delito (e nesse sentido compartilha-se do entendimento da enorme potencialidade lesiva do crime cometido, que mereceria, 'ad argumentandum tantum', melhor resposta repressiva do Estado) não pode importar no estabelecimento de situação prisional mais grave que aquela prevista em lei, porque tal postura, seja de primeiro ou segundo grau de jurisdição CONSTITUI AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO C. STF. Finalmente, em processo originário desta 20ª Vara Criminal, em julgamento da Apelação Criminal n. 0088905-16.2009.8.26.0050, de igual maneira decidiu o TJSP.

Assim, presentes os pressupostos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal, nos termos do artigo 46, parágrafo terceiro, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, segundo as aptidões do condenado, bem como na proibição de frequência a bares, boates, restaurantes e congêneres, no período noturno, pelo mesmo período, na forma do artigo 47, inciso IV, em combinação com o artigo 44, parágrafo segundo, parte final.

Em caso de descumprimento, o regime inicial será o aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LUCAS MAURICIO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput cc art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10(dez) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena pecuniária fica arbitrada no piso mínimo legal e sobre ela incidirá atualização monetária desde o fato até a quitação plena.

Deverá o réu iniciar cumprimento de pena em regime aberto.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista o regime de pena imposto.

Transitada em julgado a sentença, expeça-se a guia de recolhimento definitiva.

Autorizo a destruição da droga apreendida. Comunique-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA